

1500916-42.2021.8.26.0545

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: Laércio José Mendes Ferreira Filho

Comarca: Bragança Paulista

Foro: Foro de Bragança Paulista

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 20/01/2022

... pugnou pela absolvição do crime de tráfico, bem como postulou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para o crime de posse de drogas para uso próprio (fl. 273).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade de delito contra a saúde pública está comprovada.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 166/168) descreveu e concluiu que a ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bragança Paulista

Foro de Bragança Paulista

2ª Vara Criminal

Avenida dos Imigrantes, 1501, Bragança Paulista-SP - cep 12903-290

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500916-42.2021.8.26.0545

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2228918/2021 - DEL.INV.GER.

BRAGANÇA PAULISTA, 19791015 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 158/21/124 -

DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA, 2228918 - DEL.INV.GER. BRAGANÇA PAULISTA

Autor:

Justiça Pública

Réu:

RONALDO GOMES DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Laércio José Mendes Ferreira Filho

Vistos.

RONALDO GOMES DA SILVA foi denunciado como incurso nas sanções do artigo 33, "caput", da Lei Federal 11.343/2006, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2006, porque no dia 23 de agosto de 2021, na rua Sebastião de Moraes, nº 35, Darcilândia, nesta cidade e Comarca, tinha em depósito e guardava, para consumo de terceiros, 48 papéletes de cocaína, substância entorpecente que determina dependência física ou psíquica, sem a devida autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

Consta, também, que nas mesmas circunstâncias de tempo e espaço, RONALDO GOMES DA SILVA, possuía e mantinha sob sua guarda, no interior de sua residência, uma cartucheira sem marca aparente, de calibre 36, além de seis cartuchos íntegros e três deflagrados, de uso permitido, em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Devidamente representado, o acusado apresentou sua defesa preliminar às fls. 95/98. Recebida a denúncia aos 03 de setembro de 2021 (fl. 128), o feito seguiu o seu curso regular.

Durante a instrução processual ouviram-se três testemunhas de acusação (fls. 253 e 273) e três da defesa (fl. 273). Ao final, promoveu-se o interrogatório do acusado (fl. 273).

Em seguida, as partes apresentaram alegações finais.

A acusação requereu a procedência da ação, por entender que as provas carreadas aos autos estão em sintonia e autorizam a condenação (fl. 273).

A defesa pugnou pela absolvição do crime de tráfico, bem como postulou, subsidiariamente, a desclassificação do tráfico para o crime de posse de drogas para uso próprio (fl. 273).

É o relatório.

Fundamento e decido.

A materialidade de delito contra a saúde pública está comprovada.

O laudo de exame químico-toxicológico (fls. 166/168) descreveu e concluiu que a substância analisada é cocaína, caracterizada por meio de análises químicas e cromatográficas.

Pelos testemunhos colhidos a autoria também se revelou.

Em seu interrogatório Ronaldo admitiu a propriedade da droga apreendida em seu poder, negando, contudo, sua intenção de comercializá-la. Defendeu-se dizendo que possuía as drogas em sua residência para seu consumo pessoal, bem como que, por vezes, as utilizava na companhia de prostitutas ou garotas que frequentavam seu imóvel.

Os policiais relataram que depois de terem recebido denúncias anônimas indicando que o acusado possuía uma arma de fogo em sua residência, dirigiram-se até o local indicado.

Anote-se que não existem os registros das supostas denúncias.

Na sequência, realizaram diligência no interior do imóvel e localizaram uma arma de fogo. Disseram, ainda, que naquela ocasião após o encontro da arma, de acordo com a denúncia, estavam satisfeitos com a diligência. Todavia, o acusado também lhes informou que possuía drogas em sua casa, além de indicar o lugar onde havia guardado o entorpecente. Por fim, narraram que o acusado declarou que aquelas drogas se destinavam ao fornecimento gratuito e utilização com as prostitutas que se relacionava.

Pois bem, este é o quadro probatório dos autos.

Certo da autoria e da materialidade de crime contra a saúde pública, não ficou absoluta, latente o suficiente para ensejar a condenação, a prova a respeito do tráfico imputado. Senão vejamos.

Inicialmente verifica-se que nada há que indique que as porções de cocaína apreendidas no interior da residência do acusado estavam destinadas ao tráfico de drogas. De igual forma, o acusado não foi encontrado em situação que levasse a crer

que efetuaria o comércio espúrio.

A par disto, a denúncia anônima que levou os policiais civis a realizarem a diligência na casa de Ronaldo nada mencionou sobre o tráfico de drogas, aduzindo, apenas, que ele possuía uma arma de fogo no local.

Acrescente-se, também, que em Juízo as testemunhas de defesa ouvidas ratificaram a versão do acusado.

Rosemeire narrou que é vizinha de Ronaldo e que nunca presenciou qualquer conduta dele que indicasse o tráfico de drogas. Salientou, ainda, que sabia que ele utilizava drogas na companhia de "mulheres" que frequentavam sua casa.

No mesmo sentido foram as palavras da testemunha Vanessa. Ela confirmou que é "garota de programa" e que conhecia o acusado. Afirmou que realizou alguns programas com ele. Mencionou que o acusado é usuário de drogas e que nas vezes que esteve em sua casa ele lhe oferecia cocaína para que ela a usasse, algumas em troca do programa realizado.

Por fim, a testemunha Tamires, ex-cônjuge do acusado, salientou que nunca soube que Ronaldo fosse traficante de drogas, bem como atestou sua boa conduta social.

Repise-se que o policial civil Rodrigo mencionou que somente apreendeu as drogas na casa do acusado porque ele informou que as possuía, bem como de que, tão logo encontrou a arma de fogo no local, iria finalizar a diligência policial, quando então Ronaldo lhe confidenciou sobre as drogas e as apreendeu.

A par disto, ambos policiais civis mencionaram que não presenciaram qualquer atitude do acusado, seja no dia da prisão ou anteriormente, que indicasse seu envolvimento com o tráfico de drogas.

Por outro lado, também não se apurou se a droga apreendida seria destinada à venda, tampouco o envolvimento do acusado ficou evidenciado.

Há dúvida se o acusado dava a droga em contraprestação ao eventual programa com prostitutas ou se usava o entorpecente durante encontro com elas.

Repise-se, que a suposta denúncia informal mencionada pelos policiais indicando o armazenamento de arma pelo acusado também não é suficiente para se concluir pela prática da infração, ainda mais se levarmos em conta que a informação não trouxe nenhum relato do envolvimento do acusado no tráfico de drogas.

A par disto, com ele não foi apreendida quantidade relevante de dinheiro com origem ilícita ou qualquer outro objeto capaz de ensejar a traficância.

Desta forma, percebe-se que a prova colhida é demais frágil para sustentar uma condenação por tráfico de entorpecentes.

Não é possível condenar alguém com base apenas numa dedução, ou num mero juízo de probabilidade, assim como não é possível segregar uma pessoa por fundamento apenas suposição de que pela quantidade da droga, ela seria destinada a venda, sobretudo considerando-se a gravidade da pena prevista e o rigor da lei no que se refere à sua execução.

Nos autos estão ausentes quaisquer circunstâncias que pudessem ensejar a participação dele no tráfico de entorpecentes, como dinheiro de origem ilícita, delação concreta, materiais relacionados, etc...

A condenação de agente como incurso nas sanções previstas para o crime de tráfico de entorpecentes requer prova segura, de modo que, restando dúvidas quanto à autoria quando encerrada a instrução processual, é de se impor a absolvição, em atenção ao princípio do "in dubio pro reo", consagrado no artigo 386, VI, CPP.

Portanto, mesmo diante do encontro das drogas, nada se apurou de concreto.

Não havendo denúncia anônima concreta, apreensão de dinheiro ou qualquer outro objeto relacionado ao tráfico, como ainda, não sendo ele surpreendido em situação de venda, não há como sustentar que a droga apreendida era destinada ao comércio ilícito.

A quantidade da droga, na espécie, não é capaz de apontar a traficância, vez que é possível a utilização do material por um dependente comum, em pequeno espaço de tempo.

Assim, não há nenhuma prova ou elemento que indique que o acusado estaria guardando com ele a droga para comercialização ou entrega a terceiros. Na dúvida entre a guarda para uso próprio ou tráfico, deve se aceitar a versão do acusado.

A finalidade de traficar deve estar bem evidenciada, cristalina. A quantidade da droga, o local e a forma como foi encontrada, tudo indica para uma posse com a finalidade de uso compartilhado.

Sobre o tema este é o posicionamento de nossos Tribunais:

APELAÇÕES CRIMINAIS - Tráfico ilícito de drogas - Artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 - (i) Corréu João Pedro: Desclassificação da conduta para aquela prevista no artigo 33, § 3º, da Lei nº 11.343/2006 - Necessidade - Acusado condenado porquanto compartilhou um cigarro de Cannabis Sativa L com pessoas de seu relacionamento, de forma eventual e sem objetivo mercantil - Concordância do representante ministerial de piso - Penas cominadas no patamar mínimo legal, bem como determinação de audiência, no Juízo de piso, sobre os malefícios do uso das drogas - Sanção privativa de liberdade declarada extinta em decorrência de seu integral cumprimento (detração) - Devolução do erário apreendido - (ii) Acusado Guilherme: Recurso adstrito à dosimetria penal e ao regime prisional imposto - I. DOSIMETRIA PENAL: 1. Primeira etapa: Fixação das basilares no piso - Impossibilidade - Quantidade e natureza das drogas apreendidas que autorizam o aquilatamento - Inteligência do artigo 42 da Lei de Drogas - Aumento, contudo, ora fixado em 1/5 (um quinto) - 2. Segunda etapa: a. Afastamento da recidiva - Descabimento - Agravante comprovada nos autos - Inocorrência de bis in idem, porquanto os maus antecedentes não foram considerados para aquilatamento das básicas - b. Atenuação das penas em decorrência da confissão espontânea - Prejudicialidade - Circunstância devidamente compensada com a agravante pela recidiva - c. Reconhecimento de agravante genérica em decorrência da drogadição do recorrente - Descabimento - Circunstância que, se fosse o caso, incidiria nas hipóteses previstas no artigo 45 ou artigo 46 da Lei 11.343/2006 - Inexistência, contudo, de evidência de drogadição importante, a qual compromettesse o discernimento do acusado sobre o ilícito cometido - 3. Terceira etapa: Concessão da benesse prevista no artigo 33, § 4º, da Lei de Drogas - Descabimento - Recorrente reincidente - Óbice legal - Penas ora concretizadas em 06 (seis) anos de reclusão, além do pagamento de 600 (seiscentos) dias-multa, no piso - II. Regime prisional - Modalidade extrema que se mostrou adequada no caso vertente, mormente em face da recidiva - RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS PARA, COM RELAÇÃO AO CORRÉU JOÃO PEDRO, DESCLASSIFICAR SUA CONDUTA PARA AQUELA PREVISTA NO ARTIGO 33, § 3º, DA LEI Nº 11.343/2006, FIXANDO SUA REPRIMENDA EM 06 (SEIS) MESES DE DETENÇÃO E PAGAMENTO DE 700 (SETECENTAS) DIÁRIAS MÍNIMAS, E, AINDA, À PENA DE ADVERTÊNCIA SOBRE OS MALEFÍCIOS DO USO DE DROGAS, COM DETERMINAÇÃO DE LEVANTAMENTO DO ERÁRIO APREENDIDO, BEM COMO DE EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ DE SOLTURA CLAUSULADO E, NO QUE CONCERNE AO SENTENCIADO GUILHERME, COMINAR O AQUILATAMENTO DAS BÁSICAS DE 1/5 (UM QUINTO), REALINHANDO SUAS SANÇÕES PARA 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO, ALÉM DO PAGAMENTO DE 600 (SEISCENTOS) DIAS-MULTA, NO PISO. (TJ-SP 00005965120158260618 SP 0000596-51.2015.8.26.0618, Relator: Silmar Fernandes, Data de Julgamento: 13/11/2017, 2ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 14/11/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA USO COMPARTILHADO ART. 33, § 3º, DA LEI DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL PLEITEIA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS Impossibilidade provas produzidas não indicam com segurança o comércio ilícito desclassificação mantida. Recurso ministerial improvido e, em reformatio in mellius, redução da pena imposta ao apelado. (TJ-SP - APL: 00009568520118260210 SP 0000956-85.2011.8.26.0210, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 03/07/2013, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/07/2013)

REVISÃO CRIMINAL - Tráfico de entorpecentes - Prova contrária à evidência dos autos - Ausência de mínima prova de que a droga seria destinada à mercancia - Posse para uso próprio - Quantidade pequena de entorpecentes (5,01g de maconha) que exige prova concreta de atos de mercancia para comprovar o crime de tráfico - Desclassificação do delito de tráfico de drogas para o art. 33, § 3º da Lei 11.343/06 - Possibilidade - Manutenção da pena imposta pelo crime de uso compartilhado - Pena extinta pelo cumprimento - Revisão deferida, com expedição de alvará de soltura (voto n. 35782). (TJ-SP 22036816720178260000 SP 2203681-

67.2017.8.26.0000, Relator: Newton Neves, Data de Julgamento: 06/03/2018, 8º Grupo de Direito Criminal, Data de Publicação: 13/03/2018)

Nenhuma informação anterior existe de que o acusado pudesse ser traficante, que comerciava drogas em algum local, ou ainda, repise-se, sequer foi encontrado em situação que levasse a crer tal finalidade, a par de sua folha de antecedentes que não aponta envolvimento com o tráfico de drogas.

A desclassificação é a medida mais justa para o fato. Os fatos descritos na denúncia implicitamente abordam a conduta de possuírem substância entorpecente que causa dependência física ou psíquica, com a finalidade de uso compartilhado. O que existe nos autos é a autoria e a materialidade deste delito.

Eis a jurisprudência:

USO COMPARTILHADO DE DROGA - Agente que leva cigarro de maconha a bar, oferecendo-o a pessoas de seu relacionamento, de forma eventual e sem objetivo de lucro - Prova segura - Crime caracterizado - Pena bem dosada - Recurso a que se nega provimento (TJ-SP - APR: 00004103220168260185 SP 0000410-32.2016.8.26.0185, Relator: Mauricio Ferreira Fontes, Data de Julgamento: 15/09/2017, 1ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 19/09/2017)

USO COMPARTILHADO DE ENTORPECENTES (OBJETO DE DESCLASSIFICAÇÃO DE TRÁFICO). Recurso defensivo. Pretendida absolvição por insuficiência probatória. Autoria e materialidade bem delineadas. Pena alternativa e regime preservados. Improvimento. (TJ-SP - APR: 00258914820158260050 SP 0025891-48.2015.8.26.0050, Relator: Eduardo Abdalla, Data de Julgamento: 20/06/2018, 7ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 22/06/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. OFERTA EVENTUAL PARA USO COMPARTILHADO. PROVA. SUFICIÊNCIA.

VÍTIMA QUE CONFIRMA A OFERTA. QUANTIDADE DE DROGA INCOMPATÍVEL COM O USO

EXCLUSIVAMENTE PRÓPRIO. CONDENAÇÃO MANUTENÇÃO. A oferta eventual de droga para uso compartilhado é bem demonstrada mediante a palavra da vítima, a confirmar a oferta, amparada ainda pelo conjunto dos autos que evidencia terem sido apreendidas diversas porções individuais, incompatível com o uso exclusivamente próprio.

Sentença mantida. Recurso não provido. (TJ-SP - APR: 00015913020148260673 SP 0001591-30.2014.8.26.0673, Relator: Carlos Gustavo Urquiza Scarazzato, Data de Julgamento: 03/02/2017, 2ª Turma Cível e Criminal, Data de Publicação: 09/02/2017)

APELAÇÃO CRIMINAL SENTENÇA QUE DESCLASSIFICOU PARA USO COMPARTILHADO ART. 33, § 3º, DA LEI DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL PLEITEIA CONDENAÇÃO POR TRÁFICO DE DROGAS

Impossibilidade provas produzidas não indicam com segurança o comércio ilícito desclassificação mantida. Recurso ministerial improvido e, em reformatio in melius, redução da pena imposta ao apelado. (TJ-SP - APL: 00009568520118260210 SP 0000956-85.2011.8.26.0210, Relator: Paulo Rossi, Data de Julgamento: 03/07/2013, 12ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 05/07/2013).

Prosseguindo, a ação também procede quanto ao crime previsto na lei de armas.

A materialidade do delito de posse de arma e munições está demonstrada pelos laudos anexos (fls. 158/161 e 162/165), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 23/24) e pelo documento de ocorrência (fls.20/22).

O crime em tela visa à proteção da incolumidade pública e, secundariamente, a vida, a saúde e a incolumidade física dos cidadãos. Segundo o laudo, a arma em questão se encontrava com seu mecanismo de percussão, repetição e extração funcionando normalmente, portanto, existiu a potencialidade, atingindo assim, a objetividade jurídica do delito.

Descabe eventual alegação de que o acusado nunca usou a arma, e isto, não teria acarretado a situação de perigo prevista pela lei. A intenção do legislador é de prevenir crimes com armas, de proteger as pessoas e reduzir a criminalidade, e o acusado ao possuir e manter as armas sob sua guarda expôs a comunidade ao perigo. A circunstância de a arma de fogo não ter sido usada não exclui, por si, a tipicidade do delito porque oferece potencial poder de lesão, pois a legislação, como um todo, menciona condutas que sequer necessitariam de munição, tornando-as típicas como vender, possuir, alugar, expor à venda, fornecer, receber, etc, sendo certo que a inaptidão da arma para redundar na atipicidade deveria ser de tal natureza que excluiria, de forma absoluta, a possibilidade de lesão do bem jurídico, mostrando-se capaz de intimidar e ser usada sem maiores esforços além da

obtenção de balas, máxime se a perícia constatou sua potencialidade lesiva. O núcleo do tipo denunciado é possuir, ou seja, manter sob guarda, guardar sob seu cuidado a arma, no interior de sua residência. A confissão do acusado e a prova testemunhal são suficientes para tal comprovação.

Os Policiais Civis informaram que receberam denúncia anônima e se dirigiram até a casa do acusado, onde apreenderam uma arma de fogo.

No mais, a prova é pacífica em apontar que o acusado não possui registro válido, licença ou qualquer documentação da espingarda.

As campanhas de desarmamento são amplas e bem divulgadas e qualquer cidadão tem, por menor que seja, conhecimento de que porte, uso, guarda e depósito de armas são condutas proibidas pelo Estado.

Logo, amoldou-se o acusado ao tipo objetivo da infração imputada, ou seja, possuía arma e a munição descritas na denúncia e apreendidas pelos policiais.

A autoria é latente. As exposições acima são claras e precisas ao apontar a posse e a guarda da arma para o acusado.

Nesse sentido:

APELAÇÃO. Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido. Pleito de absolvição por atipicidade da conduta. Alegação de que a arma de fogo se encontrava em residência situada na zona rural. Pleitos subsidiários: a) substituição da pena de prestação de serviços à comunidade por pena de multa, por ser mais benéfica ao réu. 1. Condenação mantida. Prova da materialidade e de autoria. Depoimentos do policial e testemunha uniformes e convergentes. Réu confesso. Afastamento da atipicidade da conduta. Manutenção de arma de fogo em área rural que não dispensa a necessidade do certificado de registro. 2. Dosimetria da pena que merece reparos. Reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea. Conversão da pena privativa de liberdade por prestação de serviços à comunidade que não se mostra incompatível com o fato do acusado residir em área rural. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJ-SP - APR: 15001554920188260534 SP 1500155-49.2018.8.26.0534, Relator: Marcos Alexandre Coelho Zilli, Data de Julgamento: 29/07/2020, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/07/2020)

ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - POSSE ILEGAL - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INOCORRÊNCIA - ARMAMENTO DE USO PERMITIDO GUARDADO NA RESIDÊNCIA SEM O RESPECTIVO REGISTRO - CONDUTA QUE TIPIFICA O CRIME DO ART. 12, DA LEI 10.826/03 - RECURSO NÃO PROVIDO. ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - POSSE ILEGAL - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - AUSÊNCIA DE POTENCIALIDADE LESIVA E INSIGNIFICÂNCIA - INADMISSIBILIDADE - CRIME DE MERA CONDUTA E PERIGO ABSTRATO - RECURSO DESPROVIDO. "Os crimes dos arts. 12 e 16, do Estatuto do Desarmamento, são delitos de mera conduta, ou seja, consumam-se com o simples fato de portar ou possuir arma de fogo ou munição e, portanto, não exigem qualquer emprego efetivo do armamento, nem mesmo que esteja municiada ou, no caso das munições, que o agente também possua arma compatível, bastando, dentre outras ações, possuir ou deter a arma de fogo ou munição, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, pois crimes de perigo." ARMA DE FOGO E MUNIÇÕES - POSSE ILEGAL - RECURSO DEFENSIVO: ABSOLVIÇÃO - ATIPICIDADE DA CONDUTA - INADMISSIBILIDADE - HIPÓTESE QUE NÃO SE ENQUADRA NA ABOLITIO CRIMINIS TEMPORÁRIA PREVISTA NOS ARTS. 30 E 32 DA LEI 10.826/03 - AUTORIA E MATERIALIDADE SUFICIENTEMENTE COMPROVADAS - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. MUNIÇÕES DE ARMA DE FOGO - USO RESTRITO - POSSE ILEGAL - RECURSO DEFENSIVO: DESCLASSIFICAÇÃO PARA A FIGURA DO ART. 12 DA LEI 10.826/03 - INADMISSIBILIDADE - CALIBRE 7MM MAUSER - ENQUADRAMENTO COMO DE USO RESTRITO - DECRETO 10.030/2019 E PORTARIA Nº 1.222/2019 DO COMANDO DO EXÉRCITO - CONDENAÇÃO MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJ-SP - APR: 00273008820188260071 SP 0027300-88.2018.8.26.0071, Relator: Jayme Walmer de Freitas, Data de Julgamento: 02/08/2021, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 02/08/2021)

EMBARGOS INFRINGENTES E DE NULIDADE - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO (ARTIGO 12 DA LEI N. 10.826/03)- ERRO DE PROIBIÇÃO - TESE REFUTADA - ERRO NÃO CONFIGURADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - EMBARGOS INFRINGENTES IMPROVIDOS. O erro de proibição é o erro que recai sobre a ilicitude do fato, em que o agente age acreditando que não existe regra proibitiva acerca da conduta por ele praticado. Pode ser evitável ou

inevitável, sendo que apenas este último tem o condão de excluir a potencial consciência da ilicitude do agente, isentando-o da aplicação da pena prevista no preceito secundário do tipo penal incriminador. Ora, o legislador, ao estabelecer que o desconhecimento da lei é inescusável, exige apenas uma consciência potencial da ilicitude do fato. Não se trata de uma consciência técnico-jurídica, mas daquela que decorre de valores culturais, sociais e morais do indivíduo. Assim, não é crível que uma pessoa plenamente integrada à sociedade, com acesso a serviços de comunicação e informação (rádio, televisão, jornais, dentre outros), desconhecesse a proibição de se possuir arma de fogo sem a devida autorização legal, mormente após a grande repercussão gerada em torno da campanha pelo desarmamento.

Infringentes improvidos. (TJ-MS - EI: 00014420520118120002 MS 0001442-05.2011.8.12.0002, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 13/05/2014, Seção Criminal, Data de Publicação: 21/05/2014).

APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE DE ARMA DE FOGO - ERRO DE PROIBIÇÃO - INOCORRÊNCIA - IMPOSSIBILIDADE - MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA - RECURSO NÃO PROVIDO. É pouco crível que uma pessoa de diligência normal desconheça a proibição de se possuir arma de fogo sem a devida autorização legal. Ademais, não restou comprovado o desconhecimento da ilicitude da conduta. Assim, não há que se falar em erro de proibição. Recurso não provido. V.V. EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO - REGISTRO VENCIDO - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DE TAL CIRCUNSTÂNCIA PELO AGENTE - ABSOLVIÇÃO. Não comprovado o dolo consistente na ciência acerca da irregularidade da posse das armas exercida pelo sentenciado, solução outra não resta senão a reforma da sentença com a absolvição do agente. Recurso provido. (TJ-MG - APR: 10470120021519001 MG, Relator: Edison Feital Leite, Data de Julgamento: 16/10/2013, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 21/10/2013)

Concluída a motivação, à dosagem da pena devem ser atendidas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal.

Em fundamentação à aplicação da pena saliento que a reprovabilidade das condutas praticadas pelo condenado não justifica aumento nas penas-base.

Seus antecedentes não recomendam exacerbação seguindo a melhor técnica. Sua conduta social e sua personalidade não podem ser analisadas ante a ausência de elementos seguros nos autos.

Os motivos, circunstâncias e consequências dos crimes não são diferenciados a ponto de justificarem maior reprovabilidade.

Ausentes as circunstâncias judiciais que devam levar à exacerbação das penas-base, fixo-as 1 (um) ano de detenção, além de pena pecuniária em 10 (dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, para o crime de posse irregular de arma, e em 6 (seis) meses de detenção, 05 meses de prestação de serviços à comunidade e 700 (setecentos) dias-multa, em seu mínimo legal, para o crime previsto na lei de drogas.

Na segunda fase, certificada a reincidência do agente (fl. 33), observo que ela concorre com a atenuante da confissão, razão pela qual serão compensadas.

Causas gerais ou especiais de aumento ou diminuição não foram cogitadas nos autos. As penas serão somadas em razão da presença das regras do concurso material de crimes.

Para início do cumprimento da pena privativa de liberdade fixo o regime semiaberto, considerando as circunstâncias judiciais e a reincidência do agente.

O Juízo sopesa como inaplicável a consideração do tempo de prisão processual cumprido para fins de fixação do regime inicial. Isto porque se mostra inviável a aplicação da regra prevista no artigo 387, § 2º do CPP (nova redação) diante da impossibilidade de se aferir o requisito subjetivo exigido para a hipótese.

Ademais, não compete ao Juízo de cognição a questão, por se tratar de matéria restrita ao Juízo da Execução.

Nestes termos é o entendimento do Tribunal de Justiça deste Estado:

Habeas corpus. Roubo qualificado. Sentença condenatória. Detração penal nos termos do artigo 387, § 2º, CPP. Fixação de regime mais brando. Impossibilidade nesta via.

Necessidade também da aferição do requisito subjetivo: competência do Juízo das execuções criminais. Ordem denegada 'in limine'. (TJ-SP - Roubo: 20667401820148260000 SP 2066740-18.2014.8.26.0000, Relator: Alberto Mariz de Oliveira, Data de Julgamento: 13/05/2014, 16ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 16/05/2014).

Ante o exposto, e o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal, para o fim de CONDENAR RONALDO GOMES DA SILVA, qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 33, § 3º, da Lei 11.343/2006, e do artigo 12, da Lei nº 10.826/2006, à pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de detenção, no regime semiaberto, bem como à pena de PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS GRATUITOS À COMUNIDADE, pelo prazo de 05 meses, na forma dos §§ 3º a 5º, do artigo 28, da Lei 11.343/2006, a ser cumprida a medida na forma a ser designada pelo Juízo da execução e, ainda, a 710 (setecentos e dez) dias-multa, no valor, cada qual, de 1/30 do salário mínimo mensal vigente à data do fato, com correção monetária desde esta mesma data, face sua situação econômica.

Muito embora o acusado seja reincidente, o crime anteriormente praticado não foi idêntico a este, que não ostenta gravidade ou violência contra a pessoa e a substituição a pena privativa de liberdade é socialmente recomendável em razão das penas aplicadas, neste e naquele processo (artigo 44, § 3º, do Código Penal).

Assim, ante a presença dos pressupostos de aplicação das penas restritivas de direito, nos termos dos artigos 43 e seguintes do Código Penal, substituo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Primeiramente, pela de prestação de serviços gratuitos à comunidade, devendo o condenado prestar uma hora de tarefa por dia de condenação, devendo tal serviço, ainda, ser prestado aos sábados, domingos e feriados, ou dias úteis, desde que não haja prejuízo a sua jornada normal de trabalho.

Caberá ao Juiz da Execução designar a entidade ou programa comunitário ou estatal, junto ao qual o condenado irá trabalhar gratuitamente.

Ao depois, nos termos do § 1º, do artigo 45, do Código Penal, pela pena de 1 (um) salário-mínimo, a ser destinado a entidade pública ou privada com destinação social, indicada pelo Juízo da Execução.

O sentenciado poderá apelar em liberdade porque se encontra nesta condição e o Juízo não vislumbra como presentes os requisitos da prisão cautelar.

Após o trânsito em julgado, lance-se o seu nome no Rol dos Culpados.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE.

Bragança Paulista, 20 de janeiro de 2022.

LAÉRCIO JOSÉ MENDES FERREIRA FILHO
JUIZ DE DIREITO

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA